

1500052-86.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDO JOSE ALGUZ DA SILVEIRA

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... são condutas comuns aos delitos de tráfico ilícito e uso indevido, do que resulta, pelo princípio da exclusão, quando não se tratar de uso indevido, reconhecer o narcotráfico. Caracteriza o delito de tráfico ilícito de substância entorpecente trazer consigo, sem autorização legal ou regulamentar, maconha e cloridrato de cocaína, em doses unitárias, de pequenos embrulhos, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Tatuí-SP - cep 18278-440

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500052-86.2022.8.26.0571

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2006770/2022 - DEL.POL.CAPELA DO ALTO, 22334392 - DEL.POL.CAPELA DO ALTO, 17/22/311 - DEL.POL.CAPELA DO ALTO, 2006770 - DEL.POL.CAPELA DO ALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RIAN DE PAIVA FRANCO

Réu Preso

Tramitação prioritária

1º Juiz(a) de Direito Auxiliar: Dr(a). FERNANDO JOSE ALGUZ DA SILVEIRA

Vistos.

RIAN DE PAIVA FRANCO, já qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso na figura típica descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 com incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porquanto, segundo narra a denúncia, no dia 07 de janeiro de 2022, durante a tarde, na Rua Lindolfo Cleto de Moraes, nº 100 e na Rua das Flores, nº 410, na Cidade de Capela do Alto, Comarca de Tatuí, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 68 (sessenta e oito) porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 72,51 gramas, e

01 (uma) porção de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, com peso bruto aproximado de 5,9 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além da importância de R\$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais) em dinheiro.

O réu foi notificado (fl. 111) e ofertou sua defesa prévia (fls. 116/117).

A denúncia foi recebida no dia 07 de março de 2022 (fls. 118/120) e o acusado foi citado (fl. 135).

Durante audiência foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas e, ao final, o réu foi interrogado. A instrução foi encerrada e as partes apresentaram suas alegações finais em forma de debates orais (fls. 138/144).

Os autos vieram para a conclusão.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada que tramita em desfavor de RIAN DE PAIVA FRANCO, o qual, segundo consta da peça inicial acusatória, transgrediu o preceito primário da norma penal incriminadora inserida no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 com incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

Cotejadas as provas colhidas nesta ação penal, verifica-se que os fatos descritos na denúncia foram cabalmente demonstrados, de modo que, afastando-se apenas a circunstância agravante disposta no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, se impõe o acolhimento da pretensão punitiva.

Deveras, sabe-se que é necessário, para toda e qualquer condenação, que exista juízo exauriente acerca da autoria e materialidade delitiva.

A materialidade do delito está comprovada através do boletim de ocorrência de fls. 10/12, auto de exibição e apreensão de fls. 18/19, auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fl. 20, comprovante de depósito judicial de fl. 92, laudo de exame químico toxicológico definitivo de fls. 124/126 e pela prova oral colhida.

No tocante a quantidade de drogas apreendidas nos autos, importante salientar que de acordo com o laudo de exame químico toxicológico definitivo de fls. 124/126 foram apreendidas no total setenta e oito porções de cocaína e não sessenta e oito conforme consta na inicial acusatória. Referida informação é condizente com o relato dos policiais militares ouvidos em juízo. No entanto, tal fato não influi na caracterização do crime, eis que se trata de erro material que, por óbvio, não altera a dinâmica fática delineada nos autos.

De igual modo, a autoria é inconteste.

Feitas as considerações iniciais, passo à análise da prova colhida em audiência. Durante a instrução, o policial militar MARCOS GOMES disse que na data dos fatos realizava patrulhamento na companhia de seu colega da farda e, ao adentrarem na Rua Lindolfo Cleto de Moraes, avistaram o acusado vindo em direção à equipe policial. O réu, por sua vez, ao notar a presença da viatura, mudou de direção e voltou ao local do qual estava vindo. Diante da conduta suspeita, deliberaram pela abordagem. Rian possuía uma pochete contendo em seu interior dinheiro e dez envelopes de cocaína. Questionado sobre o local em que residia, inicialmente o réu mencionou morar com a mãe. Todavia, dirigiram-se ao endereço informado por Rian e os irmãos do acusado disseram que ele ali não residia e sim na companhia do seu pai. Foram até a casa do genitor do acusado. A madrasta do réu foi quem os atendeu e, posteriormente, o pai de Rian também se fez presente no local. Franqueada a entrada no imóvel, o depoente e seu parceiro localizaram em um cômodo da casa sessenta e oito porções da mesma droga apreendida com o réu, as quais estavam embaladas de forma idêntica. Também havia uma porção de maconha. Indagado pelo membro do Ministério Público, o depoente informou não se recordar se foram sessenta e oito ou setenta e oito porções de cocaína apreendidas no total. Dada a constatação da infração penal o acusado foi conduzido à Delegacia de Polícia. Não conhecia o acusado, pois passou a trabalhar no Município a menos de um ano. Questionado pela Defesa, destacou que o réu mencionou ser usuário de drogas e que trabalhava com o pai. No entanto, a madrasta afirmou que Rian não estava trabalhando com o genitor. Por fim, disse que o réu não deu explicação alguma sobre a origem do dinheiro.

A testemunha DIOGO DO NASCIMENTO, policial militar, ratificou o depoimento ofertado por seu colega de farda Marcos Gomes.

Por sua vez, perante a Autoridade Policial, o réu RIAN DE PAIVA FRANCO informou que a droga apreendida em seu poder lhe pertencia, porém era destinada ao seu consumo. Disse não praticar a venda de entorpecentes. O valor em dinheiro com ele apreendido era fruto de seu trabalho como jardineiro. Adquiriu a droga em Sorocaba, porém não sabe o nome do vendedor. É usuário de maconha e cocaína desde os seus dezessete anos de idade. Já foi internado pela prática de ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas (termo de interrogatório de fl. 06). Em seu interrogatório judicial, colhido sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa, disse ter dezenove anos de idade e possui passagem pela Vara da Infância e Juventude pela prática de ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas. Ficou internado de forma provisória. Na data dos fatos residia com seu pai, mas frequentemente ficava na casa de sua mãe e seus irmãos na Rua Antônio Correa Cleto, nº 83. Informou que seu genitor, sua madrasta e um irmão paterno residem na Rua das Flores, nº 410. Não terminou os estudos, pois precisou trabalhar com seu pai no ramo de jardinagem. Quanto aos fatos, negou a prática do tráfico de drogas. Disse ser usuário de drogas e trabalhava com o pai para sustentar seu vício. No local em que reside o valor das drogas é muito caro. Adquiria os tóxicos em Sorocaba. Comprava uma quantidade grande de drogas para não precisar retornar ao local com frequência. Indagado sobre o dinheiro com ele apreendido, afirmou recordar-se apenas da quantia de cento e vinte reais. Disse que consumia por volta de vinte a trinta porções de droga, cada uma delas com aproximadamente meio grama. Nunca teve overdose ou foi internado para tratamento de seu vício. Cada porção de droga por ele adquirida custava cinco reais. Comprava as drogas no Bairro conhecido por Morro da Sabiá. Ia até o local por meio de Uber. Recebia de seu genitor quatrocentos reais por semana. Salientou que seu pai não sabia que utilizava drogas. Novamente questionado, disse que as drogas eram por ele utilizadas juntamente com seu irmão paterno. Considera-se um usuário crônico de drogas.

Os depoimentos e o interrogatório foram captados por meio de sistema audiovisual, nos termos do Provimento CGJ 08/2011 e das Leis nº 11.419/06 e 11.719/08, e através de videoconferência, mediante utilização do aplicativo Teams/Microsoft, com a disponibilização da mídia em pasta digital, em decorrência da pandemia do Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020.

Pois bem. Diante do conjunto de provas amealhado aos autos, outra conclusão não é possível, senão a procedência da ação penal.

Finalizada a instrução, temos que o conjunto probatório leva à conclusão de que o réu é responsável pela prática do delito; a assertiva é lógica e harmoniza-se com os elementos colhidos no decorrer do feito. As porções de drogas encontradas, as circunstâncias da prisão em flagrante e as declarações dos agentes de segurança evidenciam a finalidade de tráfico.

A prova oral colhida, à luz do contraditório e as demais provas acostadas aos autos, formam um conjunto apto à formação de um juízo de convencimento quanto ao tráfico exercido pelo réu.

Vale citar: "Adquirir, guardar ou trazer consigo, sem autorização legal ou regulamentar, substância entorpecente, são condutas comuns aos delitos de tráfico ilícito e uso indevido, do que resulta, pelo princípio da exclusão, quando não se tratar de uso indevido, reconhecer o narcotráfico. Caracteriza o delito de tráfico ilícito de substância entorpecente trazer consigo, sem autorização legal ou regulamentar, maconha e cloridrato de cocaína, em doses unitárias, de pequenos embrulhos, embalagem usual do varejo das drogas" (TJRJ - AC 1.185/93 - Rel. Enéas Machado Cotta - TDTJRJ 23/288).

É cediço que a lei pune o tráfico ilícito de entorpecente em qualquer de suas condutas, típicas e exclusivas. Em tema de entorpecente, as condutas de "trazer consigo", "guardar" e "ter em depósito" sem autorização legal ou regulamentar, a droga proibida, basta para integrar a figura criminosa do tráfico ilícito. Importante, ainda, mencionar que nenhuma restrição merecem os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem do acusado, mormente quando suas

declarações vêm corroboradas por outros elementos de prova e quando não levantada qualquer suspeita fundada e demonstrada.

Nesse sentido: "... nenhum impedimento legal existe ao testemunho de investigadores e pessoas ligadas à polícia. Seus depoimentos devem ser considerados, examinados e pesados em cada caso, como o de outra testemunha qualquer. Nunca, porém, sumariamente afastados como de todo imprestáveis. Desde que verossímeis, coerentes e não desmentidos pelo restante da prova, podem servir de base à decisão condenatória." (Ap.Crim. 103.701 TJSP);

"... a simples condição de policial não torna a testemunha suspeita ou impedida" (STF - RT 68/64);

"... não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria um contrassenso credenciar o Estado alguém a atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado-Juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito." (TACRIM-SP JUTACRIM 30/221).

Portanto, o quadro probatório é eficaz e conclusivo em relação à materialidade e autoria dos fatos narrados.

A negativa do réu está em desacordo com todo o contexto probatório e, portanto, distante da realidade fática, não se prestando a influir no convencimento deste magistrado. Inexistentes nos autos quaisquer elementos tendentes a roborar sua versão.

Ficou suficientemente delineado nos autos que a equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento preventivo e, em dado momento, ao adentrarem na Rua Lindolfo Cleto de Moraes avistaram o acusado que, na ocasião, caminhava pela via pública em sentido contrário.

Ao notar a presença da viatura policial, o réu sem motivo algum rapidamente mudou seu trajeto retornando do local que estava vindo, razão pela qual os policiais militares deliberaram por sua abordagem.

Durante procedimento de revista pessoal foram encontradas dez porções de cocaína e a quantia de cento e cinquenta e cinco reais em dinheiro com o réu, acondicionados dentro de uma pochete por ele utilizada.

Os agentes públicos indagaram qual seria seu endereço, tendo o acusado inicialmente mencionado residir com a genitora. No entanto, em contato com os irmãos de Rian, eles disseram que o réu morava com o pai e forneceram o endereço correto, qual seja a Rua das Flores, nº 410.

A equipe policial dirigiu-se ao local e foi recepcionada pela madrastra de Rian que, ao tomar conhecimento dos fatos, autorizou o ingresso dos policiais no interior de sua casa.

Nas buscas realizadas no imóvel foram apreendidos dentro de um cômodo uma porção de maconha e sessenta e oito porções de cocaína idênticas àquelas encontradas em poder de Rian, individualmente embaladas e prontas para a distribuição aos usuários.

Diante da constatação da infração penal, o réu foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência.

Convém lembrar não ser preciso para a caracterização da narcotraficância que o agente seja surpreendido no exato momento em que fornece materialmente a droga a terceira pessoa, bastando circunstâncias seguras de que para tanto se destina o tóxico encontrado. E este é o caso dos autos em atenção aos elementos de informação aqui coligidos.

No mesmo sentido, não comporta acolhimento o pleito defensivo consistente na desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, porquanto nenhum elemento de informação foi apresentado a fim de fomentar a alegada condição de usuário do acusado.

Em que pese tenha o réu sugerido em juízo que é dependente químico, não apresentou qualquer documento médico ou, ainda, arrolou testemunhas que pudessem confirmar tal alegação, restando, pois, desprovida de credibilidade.

Não se olvida também que a quantidade de droga apreendida não se coaduna com a sustentada condição de dependência química.

Neste viés, inclusive, este magistrado questionou o acusado durante seu interrogatório e ele mencionou em um primeiro momento que utilizava aproximadamente vinte a trinta porções de droga. Porém, novamente indagado, informou que o uso se dava na companhia de seu irmão paterno, em uma clara tentativa de furtar-se à responsabilização penal.

Além do mais, o réu ostenta passagem pela Vara da Infância e Juventude pela prática de ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas, conforme certidão de fl. 31 e consoante por ele próprio declinado em seu interrogatório.

Sequer o acusado logrou comprovar o exercício de ocupação lícita, bem como a origem do dinheiro com ele apreendido. Embora tenha sugerido trabalhar com o pai no ramo de jardinagem, o policial militar Marcos Gomes consignou ter colhido informação da madrastra de Rian, a qual deixou claro que ele não trabalhava com o genitor.

Também se revela totalmente incompreensível a alegação de que, visando uma melhor oferta, o réu se dirija até outro Município, qual seja a Cidade de Sorocaba, valendo-se para tanto de serviço de Uber, para adquirir quantidade considerável de drogas apenas para seu consumo.

Tais questões fazem prevalecer a figura do traficante em detrimento à de usuário.

Não fosse isso, é indene de dúvidas que muitos usuários entram no tráfico para custear a compra de drogas para uso próprio (a denominada figura do "traficante-usuário"), situação que, por si só, não afasta a ilicitude do fato.

O fato de ser eventualmente usuário, afirmado apenas e tão somente na pouco crível versão do acusado, não afasta a sua relação com o comércio ilícito de drogas, pelo contrário, facilita tal espécie de atuação, diante do irrestrito acesso a outros usuários, seus consumidores e traficantes.

Neste sentido, inclusive: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade." (RJTJSP 101/498).

No mais, a Defesa não logrou trazer aos autos nenhum elemento que fosse capaz de, ao menos, colocar em dúvida algum ponto do acervo probatório constituído nestes autos, o qual se revela farto e demonstra com riqueza de detalhes toda a ação delituosa.

Inconteste, pois, a ocorrência de todos os elementos típicos, subjetivos e objetivos, necessários para a responsabilização do réu pela prática do delito disposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

DOSIMETRIA DA PENA.

Na primeira fase, observo que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao acusado.

Deixo de considerar a quantidade e a natureza da droga apreendida nesta fase, a fim de ponderá-las na terceira etapa da dosimetria da pena, notadamente para o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Justifico tal posicionamento de modo a evitar a incidência do bis in idem, em atenção ao entendimento firmado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese de que "as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena" (STF, Tema 712, publicado em 06.05.2014).

No mesmo sentido:

"Cumpru destacar que, em sessão realizada no dia 19.12.2013, o Pleno do STF, ao julgar os HCs 112.776 e 109.193, ambos da relatoria do Min. Teori Zavascki, firmou orientação no sentido de que, em caso de condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, a natureza e a quantidade da droga apreendida apenas podem ser levadas em consideração em uma das fases da dosimetria da pena, sendo vedada sua apreciação cumulativa. Na ocasião, ficou consignado que cabe ao juiz escolher em qual momento da dosimetria essa circunstância vai ser levada em conta, seja na primeira, seja na terceira, observando sempre a vedação ao bis in idem. No presente caso, o Juiz de 1º grau, ao realizar a fixação da pena, levou em consideração a quantidade e a natureza da droga tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria para elevar a pena do recorrente, o que é vedado nos termos da jurisprudência desta Corte. Assim, manifesto-me pela existência de repercussão

geral da questão constitucional debatida e pela reafirmação da jurisprudência desta Corte, de modo a fixar o entendimento no sentido de que as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena" (STF - ARE 666.334/AM; Rel. Min. Gilmar Mendes; j. 03.04.2014).

Por isso, fixo a pena-base em seu patamar mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de multa de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes.

Assim como já declinado nos autos do Processo nº 1501160-87.2021.8.26.0571, ressaltado o entendimento até então adotado por este Juízo em relação à circunstância agravante disposta no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal (crime praticado em período de calamidade pública), passo a adequar-me à orientação recorrente provinda das Cortes Superiores no tocante à natureza subjetiva da referida agravante, razão pela qual entendo a sua não incidência no caso em comento.

Neste sentido, confira-se:

"Em relação à agravante prevista no art. 61, I, "j", do Código Penal, verifica-se que a sanção do paciente foi novamente exasperada em 1/6, porque os fatos foram cometidos durante a pandemia do coronavírus, estado esse de calamidade pública; Todavia, entendo que deve ser afastada a referida agravante, pois sua incidência pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitativa." (STJ - AgRg no HC 677.124/SP; 5ª Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julgamento: 03.08.2021).

"Evidenciado, no caso, que o reconhecimento da agravante decorrente do estado de calamidade pública, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, não possui nenhum nexos com o crime praticado, inviável sua incidência, sob pena de violação à culpabilidade, em seu sentido principiológico." (STJ - AgRg no HC 669.508/SP; 6ª Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julgamento: 15.06.2021).

De igual modo, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Veja-se:

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu isolada - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena redimensionada - Afastamento da agravante da calamidade pública - Ausência de nexos causal - Regime prisional fechado mantido - Recurso parcialmente provido." (TJ-SP - Apelação Criminal nº 1501003-51.2020.8.26.0571; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal;

Relator(a): Desembargador(a) Jucimara Esther de Lima Bueno; Origem: Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal; Julgamento e Publicação: 15.02.2022).

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - APREENSÃO DE 47,1 GRAMAS DE COCAÍNA E 21,5 GRAMAS DE MACONHA - MERCANCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO CORRETA, POIS LASTREADA EM PROVA FIRME DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PENAS - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ALÍNEA "j" (calamidade pública) - NECESSIDADE. Não há prova de que o réu se valeu da pandemia causada pelo COVID-19 para praticar o delito - PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO." (TJ-SP - Apelação Criminal nº 1501141-18.2020.8.26.0571; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Relator(a): Desembargador(a) Willian Campos; Origem: Foro de Tatuí - 1ª Vara Criminal; Julgamento e Publicação: 01.09.2021).

O réu faz jus à atenuante disposta no artigo 65, inciso I, do Código Penal, eis que à época dos fatos era menor de vinte e um anos de idade. No entanto, em atenção à Súmula nº 231 do STJ, deixo de valorá-la, pois a pena nesta etapa não pode ficar aquém do mínimo legal, razão pela qual a pena intermediária permanece inalterada. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Inviável a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, eis que o réu dedica-se ao comércio ilícito desde a menoridade.

Com efeito, infere-se do seu interrogatório e da certidão de fl. 31, ostenta passagem pela Vara da Infância e Juventude, notadamente pela prática de ato infracional análogo ao crime em questão.

De fato, é certo que registro de ato infracional não se presta a gerar maus antecedentes ou reincidência. Não obstante, é apto e suficiente para afastar a incidência do tráfico privilegiado, pois denota que sua conduta tem sido permeada pela prática de atos antissociais.

Neste viés, inclusive, "... conquanto o ato infracional (...) não possa ser considerado para fins de reincidência, ou mesmo como maus antecedentes, serve perfeitamente para demonstrar sua periculosidade, bem assim sua propensão ao cometimento de delitos da mesma natureza (...)" (HC 33614/DF; 5ª Turma; Rel. Min. Laurita Vaz; j. 2-6.2005; DJ 20-6-2005; p. 302). "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A QUATRO E NÃO EXCEDENTE A OITO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RÉU PRIMÁRIO. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DO ENTORPECENTE. MODO INTERMEDIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. MANIFESTA ILEGALIDADE PARCIALMENTE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art. 33, § 4º, da Lei n.11.343/2006). 3. Concluído pela instância antecedente, diante de anterior registro de ato infracional análogo ao delito de tráfico de entorpecentes, que o paciente se dedica a atividade criminosa, a alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes. (...)" (HC 435.685/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018) - destaquei.

Não bastasse, a quantidade e natureza da droga apreendida (setenta e oito porções de cocaína com peso bruto de 56,37 gramas e líquido de 35,52 gramas; e uma porção de maconha com peso líquido de 2,31 gramas) revela expressiva, denotando ser incabível a concessão do privilégio legal.

Acerca do tema, inclusive:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ENVOLVIMENTO NA TRAFICÂNCIA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAFASTÁVEL A INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL) DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME INICIAL FECHADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. IMPOSIÇÃO JUSTIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal a quo negou o benefício, concluindo que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa do tráfico, diante da quantidade e da natureza droga apreendida e das circunstâncias do fato, de maneira que entender diversamente, como pretendido, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Inafastável a aplicação do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 2. Esta Corte tem decidido que a quantidade e a natureza da droga, aliadas às circunstâncias em que cometido o tráfico, podem evidenciar a dedicação a atividades criminosas, o que afasta a aplicação da minorante. In casu, a utilização da quantidade/natureza da droga apreendida para elevar a pena-base (primeira fase) e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (terceira fase), por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, não configura bis in idem. Diversa é a

hipótese tratada no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade/natureza da droga “tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006” (ARE 666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014). 3. A quantidade e natureza da droga apreendida – 500 invólucros de cocaína e 9 porções de maconha – constituem fundamentos idôneos para o agravamento do aspecto qualitativo da pena, ou seja, para a fixação de regime mais gravoso (fechado). 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 1630521 SP 2019/0362668-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: DJe 09/06/2020) - destaquei. “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PACIENTE CONDENADO À PENA CORPORAL DE 5 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME PRISIONAL FECHADO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. CONDENAÇÃO PROVISÓRIA ANTERIOR. OFENSA À SUMULA N. 444 DESTA CORTE. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE DEDICA-SE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MONTANTE DA PENA QUE NÃO PERMITE O BENEFÍCIO. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E PRIMARIEDADE QUE ENSEJAM O REGIME INICIAL SEMIABERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) - Esta Corte Superior tem decidido que a quantidade, a variedade e a nocividade da droga, bem como as circunstâncias nas quais foi apreendida, são elementos que evidenciam a dedicação do réu à atividade criminosas e, em decorrência, podem embasar o não reconhecimento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. - Hipótese em que inexistente ilegalidade quando da não aplicação do privilégio, pois a Corte local apontou a dedicação do paciente às atividades ilícitas, destacando a quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos e as circunstâncias em que o delito ocorreu, notadamente agravadas pelo fato de o acusado contar com condenação provisória pela prática do mesmo delito e por terem sido apreendidos 536 tubos plásticos vazios. Modificar tal conclusão requer o revolvimento fático probatório, inviável na estreita via do habeas corpus. Precedentes.” (STJ, HC 374992 / SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 07/02/2017) - destaquei. De fato, a cocaína possui efeitos deletérios àqueles que dela fazem uso com alta probabilidade de dependência imediata e catastrófica após a sua ingestão, bem como se apresenta extremamente nociva à sociedade como um todo, tornando-se um problema endêmico de saúde pública em todo o território nacional. Acrescente-se que o benefício previsto no § 4º, do artigo 33, não pode ser aplicado indistintamente, devendo ser aplicado aos casos específicos, ou seja, desde que preenchidos os seus requisitos, cuja interpretação é realizada de forma restritiva, a fim de se prestigiar aquele que real e efetivamente mereça ser beneficiado com a redução da pena, o que não é o caso do acusado, à vista do quanto aqui ponderado. Portanto, a reprimenda fica estabelecida de forma definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de multa de 500 (quinhentos) dias-multa. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E BENESSES LEGAIS. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por restarem não atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal; o regime de cumprimento fixado para o tráfico de entorpecentes e a própria natureza do delito, que é móvel de grande parte de outros crimes cometidos para a manutenção do vício, impedem a concessão da benesse por restar desatendido o inciso III do dispositivo legal retro mencionado. Pelas mesmas razões, resta desatendido o inciso II do art. 77 do Código Penal, inviabilizando a suspensão condicional da pena. Fixo, como regime inicial de cumprimento de pena para o delito de tráfico de drogas, observadas as colocações feitas por ocasião da não substituição da pena privativa, o REGIME FECHADO, único que se mostra compatível com a gravidade do delito e sua potencialidade lesiva.

Ainda quanto a fixação do regime inicial fechado, colhem-se os seguintes julgados proferidos pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“TRÁFICO DE DROGAS PEDIDO SUBSIDIÁRIO - FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO INADMISSIBILIDADE - REGIME INICIAL FECHADO ADEQUAÇÃO À ESPÉCIE DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO - INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 11.464/2007. “Ressalto que há determinação expressa no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, de que as penas por crime hediondo ou equiparado iniciam-se no regime fechado”. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ/SP. AP 0057527-71.2011.8.26.0050. Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator: Marco Antonio Marques da Silva; Data do julgamento: 27/06/2013) - sem destaques no original;

“No concernente ao regime prisional impositivo à espécie, também se mostra correta a fixação do inicial fechado (Lei nº 11.464/07), por duas razões principais: a uma, porque o regime fechado foi determinado de forma precisa e correta, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal e, a duas, porque o crime de tráfico de entorpecentes equiparado a hediondo, não se sujeita a regime mais brando, pois, como público e notório, provoca o recrudescimento da violência e da intranquilidade social, além da desagregação da instituição familiar” (TJSP AP. nº 990.09.042255-6 Rel: Des. Paulo Rossi) - sem destaques no original;

“Tráfico de drogas Recurso defensivo pleiteando a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 e a fixação do regime prisional aberto - Provas francamente incriminadoras - Condição de usuário que não elide a concomitante atividade de traficância - Crime de perigo abstrato, não se exigindo que o infrator seja flagrado no próprio ato de venda da mercadoria proibida. Pena que não comporta reparo. Réu beneficiado com a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Regime prisional fixado com critério - Crime equiparado a hediondo, ensejando a aplicação, inicialmente, de um regime mais severo, mostrando à sociedade a eficaz repressão a esse tipo de delito - Personalidade deturpada, causadora de risco à ordem pública, de quem envereda para a prática desse tipo de criminalidade - Inaplicabilidade do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal - A competência para se discutir a respeito da detração penal é do juízo das execuções - Negado provimento.” (TJSP. AP nº 0001719-19.2014.8.26.0263, Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal. Relator(a): Fernando Simão. Data do Julgamento: 10/09/2015) - sem destaques no original.;

“Tráfico de entorpecentes. Réu que, em local conhecido como ponto de venda de drogas, ao pressentir a iminência da abordagem por guardas municipais, desvencilha-se de sacola contendo 6 porções de maconha, 19 porções de cocaína e 82 pedras de crack. Localização, em seu poder e ao ensejo de revista, de R\$ 62,00 sem comprovação satisfatória de origem. Palavras dos guardas municipais coerentes e harmônicas. Versões exculpatórias dissonantes e das mais inconsistentes. Alegação de flagrante forjado repelida. Destinação mercantil das drogas bem evidenciada. Pleito de desclassificação da conduta repelido. Condenação, pelo tráfico, bem decretada. Penas que já beneficiam o acusado. Redução, com lastro no artigo 33, § 4º, não questionada pela acusação. Substituição da pena corporal por restritivas de direitos incompatível com crime equiparado a hediondo. Regime fechado necessário e decorrente, inclusive, de lei (Lei nº 11.464/07). Apelo improvido.” (TJ/SP. AP 0071629-66.2012.8.26.0114. Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal. Relator(a): Pinheiro Franco. Data do julgamento: 04/07/2013) - sem destaques no original.

E, ainda, o quanto já decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: “O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do problema de segurança que atormenta os moradores das cidades. E se o Juiz é, como deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não pode deixar de considerar a importância de suas decisões na contenção da onda de violência que se vem alastrando de maneira quase incontornável, alarmando a população e intranquilizando familiares”. (In RTJ 123/547).

Soma-se a tal que é de entendimento deste juízo, em casos como este, quanto a dever ser rigorosa a repressão ao delito em tela, não havendo que se descurar, inclusive, que os supramencionados dispositivos constitucionais e legais, encontram pleno

amparo na Convenção de Viena, de 1991, de Combate ao Tráfico de Drogas, promulgada no país pelo Decreto nº 154/91, especialmente aos seus artigos 4º, "a", 6º e 7º. Atento a tais características do delito praticado, a quantidade de pena e regime impostos, reputo necessária a manutenção custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, motivo pelo qual, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade.

No sentido exposto, o magistério de Júlio Fabrini Mirabete (Código de Processo penal Comentado, 6ª Edição, RT, p. 590), in verbis:

"O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional".

E, ainda, no seguinte julgado, in verbis:

"Há lesão à ordem pública quando os fatos noticiados nos autos são de extrema gravidade, causando insegurança jurídica a manutenção da liberdade do acusado".

(STF, HC nº 90.726, Rel. Min. Carmem Lúcia, v.u.).

Ausentes nos autos informações acerca da situação econômica do réu, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato, corrigido monetariamente desde então.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, decotando a circunstância agravante disposta no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu RIAN DE PAIVA FRANCO, qualificado nos autos, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de multa de 500 (quinhentos) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 com incidência da circunstância atenuante disposta no artigo 65, inciso I, do Código Penal.

CONFORME JÁ FUNDAMENTADO, NEGADO O APELO EM LIBERDADE. RECOMENDE-SE O RÉU JUNTO AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM QUE SE ENCONTRA RECOLHIDO.

Com relação à detração penal como parâmetro para estabelecimento do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, mercê do que dispõe o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, urge proceder-se a uma interpretação sistemática da norma, atentando-se que o estabelecimento do regime inicial é pautado também pelas circunstâncias do delito (artigo 33, do Código Penal). Neste cenário, a detração constitui fator a ser considerado para fins de progressão e acompanhamento do cumprimento da pena aplicada na fase da Execução.

Autorizo a incineração da substância entorpecente, caso tal medida ainda não tenha sido providenciada.

DECLARO o perdimento do numerário apreendido, qual seja a quantia de R\$ 155,00 (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 18/19 e comprovante de depósito judicial de fl. 92), em favor da União, para ser revertido diretamente ao Funad, nos termos do artigo 91, inciso II, alíneas "a" e "b", do Código Penal c.c. o artigo 63 e parágrafos, da Lei nº 11.343/06.

O réu está assistido por Defensor nomeado, circunstância que gera a presunção de não dispor de recursos para custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Assim, incabível se mostra a condenação ao pagamento das custas.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários ao Advogado que atuou no feito patrocinando os interesses do réu (fl. 112), nos termos do Convênio DPE/OAB.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema

Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva,

remetendo-a ao Juízo competente e demais comunicações necessárias.

P.I.C.

Tatui, 22 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA